

1502295-79.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/3 NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502295-79.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502295-79.2020.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANTHIAGO FRAGA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

SANTHIAGO FRAGA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II e artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal porque, no dia 26 de julho de 2020, por volta de 21h10min, na Rua Dom Lara, nº 141, Vila Valença, nesta cidade, em ocasião de calamidade pública, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair uma bicicleta pertencente a R.C.

Recebida a denúncia, o acusado foi citado e ofereceu resposta à acusação.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha policial arrolada na denúncia, sendo homologada a desistência manifestada pelas partes quanto à oitiva da testemunha policial José Roberto. Ao final, o acusado foi interrogado.

Instaurado incidente para verificação de dependência toxicológica, a pedido da Defesa, o laudo pericial foi juntado às fls. 159/162.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do réu pela prática do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, porém em sua forma consumada e majorado pela causa de aumento relativa ao repouso noturno. Formulou, ainda, pedidos relativos à dosimetria da pena e ao regime prisional.

A Defesa, por sua vez, deixou de requerer a absolvição do acusado, em razão de sua confissão. Pugnou pela desclassificação do delito para sua forma simples, com o afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo. Formulou, ainda, pedidos relativos à fixação da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da circunstância agravante relativa ao estado de calamidade pública, o reconhecimento da circunstância atenuante relativa à confissão, o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno e, por fim, o reconhecimento da tentativa. Pleiteou, ainda, a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de furto descrito na denúncia está bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial de fls. 107/109, bem como pelos demais elementos constantes nos autos.

A autoria também é certa.

Interrogado em Juízo, o acusado admitiu o furto da bicicleta, mas negou ter quebrado o cadeado. Disse que havia somente uma corrente entrelaçada no portão, sem nada o trancando, nem mesmo maçaneta. Contou que foi detido a poucos metros da casa pela vítima e populares, sem ter retirado a bicicleta de dentro do imóvel. Disse que tentou praticar o crime para comprar crack, droga que usa com frequência, e declarou já ter permanecido internado em clínica para tratamento de sua dependência.

Corroborando a confissão do réu quanto à subtração da bicicleta, a vítima, quando ouvida sob o crivo do contraditório, declarou que estava na sala de sua casa com familiares, assistindo à TV, em um domingo à noite, quando ouviu um barulho e, ao olhar para o quintal, viu um indivíduo subtraindo sua bicicleta, que ali estava. Disse que gritou e o meliante empreendeu fuga, em posse da bicicleta. Relatou que foi ao encalço do meliante, com seu irmão e seu cunhado, gritando “pega ladrão”, e aquele tentava subir na bicicleta para pedalar, mas sem sucesso, até que a dispensou e, na esquina, vizinhos cercaram o acusado e o contiveram até a chegada da polícia ao local. Declarou que a bicicleta subtraída tinha o valor aproximado de R\$300,00 e foi recuperada. Consignou que, dez dias antes, durante a madrugada, já havia ocorrido um furto em sua casa, em que parte da maçaneta de seu portão havia sido quebrada, e duas bicicletas haviam sido subtraídas. Esclareceu que, pelas câmeras de segurança, o meliante nas duas ocasiões parecia ser a mesma pessoa e entregou tais imagens à Autoridade Policial. Afirmou que, na data dos fatos descritos na denúncia, a maçaneta, que já havia sido consertada, foi novamente quebrada, tendo sido quebrado também o cadeado com corrente que prendia as duas folhas do portão. Relatou que uma chave de fenda foi encontrada no local dos fatos após a fuga do meliante. Reconheceu o acusado em Juízo como sendo o mais semelhante ao autor do crime, esclarecendo que, na data dos fatos, ele estava mais magro. Afirmou, por fim, que, na data dos fatos, não teve dúvidas em reconhecer a pessoa detida como sendo aquela que havia subtraído a bicicleta de sua casa.

A testemunha policial militar João Gabriel Aragão Cirino, ouvida em Juízo, relatou que, noticiado pelo Copom um furto em andamento, foi ao local indicado, onde o réu

já estava detido por populares e pela vítima. Soube pela vítima que ela estava em casa, quando ouviu um barulho vindo do portão, possivelmente quando o cadeado foi rompido, e viu o acusado dentro da casa, furtando uma bicicleta que estava na garagem. Indagado, o acusado admitiu, informalmente, a prática do crime. Declarou que o réu não aparentava estar sob a influência de alguma substância química. Relatou que o acusado foi detido a alguns metros da casa onde o furto foi cometido. Não conhecia o réu anteriormente aos fatos.

Em face de toda a prova carreada aos autos, diante das declarações da vítima e do relato da testemunha policial militar, os quais foram fornecidos com segurança e detalhes, e que corroboraram a confissão do acusado em Juízo, não há dúvidas em se concluir que este efetivamente praticou o delito de furto.

Embora a confissão não seja prova dotada de caráter absoluto, no presente caso, ela está em conformidade com os demais elementos coligidos aos autos, tendo sido confirmada pelos depoimentos judiciais da vítima e do policial militar que realizou sua prisão em flagrante.

Veja-se que a vítima bem esclareceu que viu o réu no interior de sua casa e o viu evadir-se em posse de sua bicicleta, até ser contido com o auxílio de vizinhos, reconhecendo-o sem dúvidas como o autor do crime.

Frise-se que deve ser dada normal credibilidade às declarações apresentadas pela vítima, uma vez que não restou demonstrado nos autos ter ela intenção de prejudicar o réu. O depoimento foi firme e inequívoco, não havendo razões para se duvidar do que foi dito por ela. Nesse sentido:

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250)

"Tribunal de Alçada Criminal - TACrimSP. PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que confortada por outros elementos probatórios, como o depoimento de uma testemunha, reveste-se de total importância." (TACrimSP - Ap. nº 1.157.791/5 - Araraquara - 10ª Câmara - Rel. Ary Casagrande - J. 2.2.2000 - m.v)."

Quanto ao testemunho do agente policial, com enorme grau de confiabilidade, também presta-se a viabilizar a condenação do acusado.

Em relação ao valor probatório do depoimento de testemunha policial destaca-se o seguinte entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais -Validade. O valor do

depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1a Turma - HC n. 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

Dessa forma, o crime de furto e sua autoria restaram bem demonstrados nos autos.

De outro lado, pelos elementos constantes dos autos e diante do consolidado entendimento dos Tribunais Superiores que prestigia a Teoria da Apprehensão, verifica-se que o furto foi consumado, uma vez que o acusado conseguiu apoderar-se da res, invertendo a posse, independentemente de ter sido esta tranquila, mansa e pacífica.

Incide na espécie o Enunciado da Súmula nº 582 do E. Superior Tribunal de Justiça: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada."

E nesse sentido, confirmam-se as decisões que confirmam o mesmo entendimento quanto ao delito de furto:

"Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I - A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desviada da coisa pelo agente. Precedentes. II - O elevado grau de reprovabilidade de conduta criminosa praticada por militar no interior de organização militar impede a aplicação do princípio da insignificância. III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. IV - Habeas Corpus denegado." (HC 135674, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 11-10-2016 PUBLIC 13-10-2016) (grifos nossos)

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO. INVERSÃO DA POSSE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA 582/STJ. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DETRAÇÃO. AINDA QUE APLICADA, NÃO REDUZIRIA A PENA PARA PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS. REGIME MAIS GRAVOSO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. IRRELEVÂNCIA DO EVENTUAL APROVEITAMENTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a

possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O delito de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por poucos instantes, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem. Dessa forma, prevalece, tanto nesta Corte Superior quanto no Supremo Tribunal Federal a teoria da amotio ou apprehensio. 3. Inclusive, esse entendimento foi consolidado recentemente no enunciado n. 582 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 4. Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". 5. Na hipótese, o aumento da pena em fração superior ao mínimo, em razão da incidência de três majorantes, decorreu de peculiaridades concretas do crime - cinco agentes envolvidos na empreitada criminosa, com emprego de arma de fogo, com invasão de domicílio, e amarração de duas vítimas. Em tais condições, fica afastada a aplicação do enunciado n. 443 da Súmula desta Corte. 6. "Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito" (enunciado n. 440 da Súmula do STJ) e, no mesmo sentido, os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do STF. 7. No caso, embora os pacientes sejam primários, condenados à pena privativa de liberdade superior a 4 e não excedente a 8 anos, o regime mais gravoso foi estabelecido mediante fundamentação concreta, qual seja, ameaça a duas vítimas, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e mediante invasão de domicílio. 8. O cômputo da prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial, conforme o comando do § 2º do art. 387 do CPP, demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal. 9. No caso, verifica-se que, mesmo aplicada a regra da detração, o tempo de prisão provisória não reduziria a pena para patamar inferior a 4 anos, sendo o regime mais gravoso fixado com base em fundamentação concreta, razão pela qual a efetiva detração de eventual pena cumprida de forma provisória seria irrelevante. 10. Habeas corpus não conhecido." (HC 362.436/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016) (grifos nossos)

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. MOMENTO CONSUMATIVO. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática for proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP. 2. Esta Corte adotou o entendimento no sentido da teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual os crimes de roubo e de furto, consumam-se no momento em que os agentes se tornam possuidores da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve espaço temporal, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica, tranquila ou mesmo desvigiada. 3. "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (REsp 1524450/RJ,

Representativo da Controvérsia, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 29/10/2015) . Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 787.872/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 31/08/2016) (grifos nossos)

Dessa forma, está-se diante da hipótese prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal, o qual prescreve que o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da queixa ou da denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Há que se esclarecer que, no Processo Penal, vige o princípio do jura novit curia ou princípio da livre dicção do direito. Em outras palavras, vigora o princípio da consubstanciação narra mihi factum dabo tibi jus. Isso significa que o réu não se defende da capitulação legal dada ao crime na denúncia, mas dos fatos que nela estão descritos.

Dessa forma, como bem leciona Julio Fabbrini Mirabete, ao explicar o princípio da emendatio libelli contido no artigo 383 do Código de Processo Penal, em seu Processo Penal, 10ª edição, pág. 453:

"No caso, o juiz, verificando que estão comprovados os fatos e as circunstâncias narradas na peça inicial, pode condenar o acusado dando ao delito a definição jurídica que entende cabível e não aquela articulada na denúncia, inclusive com aplicação de pena mais grave. A definição jurídica a que a lei alude é a classificação do crime, é a subsunção do fato à descrição abstrata em determinado dispositivo legal, inclusive quanto às circunstâncias de infração legal. Compreende-se que essa definição seja alterada pela sentença porque o acusado se defende do fato criminoso que lhe é imputado e não dos artigos de lei com que ele é classificado na peça inicial."

É exatamente o que ocorre nos presentes autos. A descrição dos fatos contida na denúncia, quanto ao apoderamento da res pelo acusado, está clara e objetiva, sendo necessária apenas uma corrigenda quanto à capitulação legal.

Trata-se, portanto, de furto consumado.

A qualificadora do rompimento de obstáculo foi suficientemente comprovada pelo laudo pericial de fls. 107/109, que deve ser analisado conjuntamente com as declarações da vítima. Note-se que o exame realizado na corrente com cadeado demonstrou a quebra deste e a vítima afirmou que a corrente com o cadeado - que foram quebradas pelo acusado naquela data - guarneciam o portão, prendendo suas duas folhas.

Finalmente, evidenciado que o crime foi cometido durante o repouso noturno, em horário em que a população ainda está recolhida e em horário de menor vigilância sobre os bens, o que, conseqüentemente, ocasiona a maior vulnerabilidade do patrimônio

Todavia, recente decisão proferida pela 3ª Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, tema 1087, no julgamento do REsp nº 1.888.756/SP, afastou a incidência desta causa de aumento de pena aos furtos qualificados, fixando a seguinte tese:

"A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)."

Por esta razão, fica afastada a majorante no presente caso.

Observe-se, entretanto, que, no v. Acórdão proferido nos autos do Recurso Especial acima aludido, destacou-se a possibilidade de consideração do repouso noturno como circunstância judicial que agravaria a pena, por se tratar efetivamente de circunstância mais grave em comparação ao delito praticado em horário diverso ou mesmo em comparação a um furto simples perpetrado durante o repouso noturno.

Veja-se:

"Deve-se registrar também que o princípio da proporcionalidade destina-se igualmente a evitar a proteção insuficiente ou deficiente dos bens jurídicos resguardados pelo Direito Penal. Ora, é evidente que a lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno é maior que a do furto simples ocorrente no mesmo período. Assim, é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto."

Desta maneira, restou provada a prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Passo, portanto, a dosar a pena.

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, diante das circunstâncias do crime, conforme já ressaltado, tendo o acusado cometido o furto durante repouso noturno, e observando-se que o acusado ostenta maus antecedentes, conforme certidão criminal de fls. 21/28, aumento a pena-base em 1/3, fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor de cada dia-multa no mínimo legal, devendo ser corrigido desde a data dos fatos.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico que o réu é reincidente pela prática de mesma espécie de delito (certidão criminal de fls. 23 - Processo nº 0008258-67.2016.8.26.0477), motivo pelo qual aumento sua pena em 1/3, ficando em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor já estabelecido.

Sobre o montante de aumento:

"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/3 NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A reprimenda imposta ao paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador, sendo a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da natureza, quantidade e variedade das drogas. Precedentes. 3. Possibilidade de agravamento da pena em 1/3, na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência específica. 4. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HABEAS CORPUS HC 305029 SP 2014/0244748-0 (STJ). 5ª T. Rel. Min.

GURGEL DE FARIA. Julg. 25/11/2014. Public. 03/12/2014)

Verifico, ainda, que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal em 1/6, ficando a pena fixada em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Não é possível o reconhecimento da confissão espontânea no presente caso, pois foi parcial, e feita com o nítido objetivo de se beneficiar com tipificação mais branda para sua conduta, com o afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo e com o reconhecimento da forma tentada do crime.

Como ensina Mirabete, não basta "a simples confissão para que se configure a atenuante; exige a lei que ela seja espontânea, de iniciativa do autor do crime, e que seja completa e movida por um motivo moral, altruístico, demonstrando arrependimento" (in Código Penal Interpretado, 5ª ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2005, p. 517).

Nesse sentido:

"CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE - Confissão espontânea parcial - Reconhecimento - Impossibilidade: - A confissão parcial, imbuída de maliciosa negativa de circunstâncias agravantes, não dá lugar à incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do CP." (Apelação nº 1.170.253/9 - São Paulo - 7ª Câmara - Relator: Corrêa de Moraes - 3/2/2000 - V.U.)

"Em se tratando de atenuante da confissão, o agente que buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do requisito da espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação das penas, confissão pela metade". (RJTACRIM 33/56)

(...) Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea - Impossibilidade - Confissão parcial externada pelo réu com o intuito de se eximir de responsabilização criminal (...). (TJSP, 0004729-51.2015.8.26.0129, Relator(a): Juvenal Duarte; Comarca: Casa Branca; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 01/12/2016; Data de registro: 05/12/2016);

(...) Confissões parciais. Reconhecimento da atenuante. Impossibilidade. (...). (TJSP, 0000441-82.2015.8.26.0542, Relator(a): Luiz Fernando Vaggione; Comarca: Carapicuíba; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 16/01/2017; Data de registro: 18/01/2017);

(...) Confissão parcial que não tem o condão de atenuar a reprimenda (...). (TJSP, 0003652-50.2015.8.26.0050, Relator(a): Cesar Mecchi Morales; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/01/2017; Data de registro: 18/01/2017).

Na última fase do cálculo da pena, não incidem causas de aumento ou de diminuição, ressaltando-se que o laudo pericial relativo ao exame para verificação de dependência toxicológica concluiu que o acusado era capaz de entendimento e determinação à época dos fatos, portanto, imputável.

À míngua de outras causas de modificação, torno definitiva a reprimenda acima

estabelecida.

Fixo o regime fechado como regime inicial do cumprimento da pena, diante da reincidência do acusado, bem como das circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena, diante dos maus antecedentes e da reincidência do réu, bem como é incabível o sursis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu SANTHAGO FRAGA CRUZ, qualificado nos autos, às penas de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, incidente a correção monetária, por infração ao disposto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, já que ausentes os requisitos da custódia cautelar.

Ausente demonstração mínima dos integrais prejuízos sofridos pela vítima, bem como pela ausência de pedido nesse sentido na denúncia, deixo de condenar os réus nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do direito de reparação do ofendido a ser perseguido na esfera cível.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 14 de outubro de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA